

Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

PROCESO VERBAL - Desarrollo de todos los principios procesales y administrativos

Recuérdese que la H. Corte Constitucional ya ha analizado en varias oportunidades la constitucionalidad de los procesos verbales y ha determinado que los procedimientos disciplinarios verbales son Constitucionales y desarrollan a plenitud todos los principios procesales y administrativos consustanciales de la función pública, referentes a la celeridad, eficacia, economía procesal, inmediación y concentración de las audiencias y oralidad, siendo las principales características del procedimiento verbal de responsabilidad disciplinaria, contemplado en las disposiciones reglamentarias del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 29 y 209 Superiores.

Para la H. Corte Constitucional, el procedimiento verbal garantiza una mayor eficiencia y celeridad al proceso disciplinario, en la medida en que permite un desarrollo más ágil a los casos contemplados en la ley. Esto le da fortaleza y equilibrio al proceso porque permite que el proceso termine en un periodo más corto, dando mayor credibilidad a la administración de justicia.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 94 Y 175

EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES – Desborde de las facultades propias de su cargo.

Por otra parte si se aceptara en gracia de discusión por este sensor de instancia que en efecto el funcionario no se encontraba en ejercicio de sus funciones al efectuar las conductas reprochadas, se estaría en desconocimiento del propio artículo 6 de la Constitución Nacional que impone a los funcionarios públicos responsabilidades no solo por el incumplimiento de la ley, sino por la omisión o la extralimitación de sus funciones, entendida dicha extralimitación en el ámbito penal y en advenimiento normativo al derecho disciplinario, como el hecho de que el servidor público desborde las facultades propias de su cargo, asumiendo o desempeñando funciones diferentes a las otorgadas por la ley o el reglamento¹, así como también se desconocerían las premisas del artículo 121 de la Carta Política cuando establece que “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”, seguido del artículo 122 al preceptuar que “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o el reglamento”.(Subrayas del despacho).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION NACIONAL- ARTICULO 6 / LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 50.

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, MP Carlos Eduardo Mejía Escobar, Sentencia de julio 22 de 1998, expediente de única instancia No. 6989.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2013-0235
Número y fecha del fallo:	0009 del veintiuno (21) de abril de dos mil catorce (2014)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmado en segunda instancia

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado (XXX), en su condición de defensor de confianza del procesado (XXX), en contra del fallo sancionatorio proferido en audiencia, celebrada por la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de esta Agencia ITRC, el pasado 18 de marzo del año en curso.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 00985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

- 1.- Los hechos investigados en la presente actuación disciplinaria, tuvieron su origen en el Oficio No.132000201-0784 del 14 de agosto de 2013, suscrito por la Directora Seccional de Impuestos de Bogotá, doctora (XXX), en el cual informó que la señora (XXX), se presentó en dichas instalaciones el día 12 de agosto de 2013 exhibiendo el auto comisorio No. 32-241-418-2013-091653 del 5 de agosto de 2013, el cual le fue entregado en copia por su hermano (XXX), en calidad de contribuyente objeto de visita, para que indagara respecto de la validez del acto administrativo referido y presuntamente delegado al funcionario (XXX), para adelantar la actuación administrativa allí referida.
- 2.- Tras entrevistarse con la Jefe del Grupo de Obligaciones formales de la División de Gestión de Fiscalización para Personas Naturales, funcionaria (XXX), se estableció que el presunto auto comisorio era falso, por cuanto presentaba en su cuerpo motivo y resolutivo varias inconsistencias como en los nombres y cargos de los funcionarios, entre otros.
- 3.- Relata el informe, que horas más tarde recibió una llamada telefónica en la que se le informó que la policía había capturado a la persona que se presentó con el auto comisorio en dicho establecimiento de comercio y que se encontraba siendo trasladado a la URI de Paloquemao, así mismo que se trataba de un funcionario de la DIAN, ante lo cual decidió enviar en representación de la entidad al Jefe de la Unidad Penal y al Jefe del Grupo de

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

Obligaciones Formales del grupo de Fiscalización de Personas Naturales a presentarse en el complejo judicial de Paloquemao y sobre las 16 horas el despacho de la Dirección recibió la noticia de que se trataba del funcionario (XXX), adscrito a dicha Seccional de la Dian.

4.- Por los hechos aquí relatados, la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de esta UAE Agencia ITRC, mediante auto del 16 de agosto de 2013², dispuso la apertura de indagación preliminar con el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos denunciados en el informe servidor público³, verificar si estos constituían falta disciplinaria o si se había actuado al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad, en los términos del artículo 150 de la ley 734 de 2002. La anterior decisión, fue notificada personalmente al implicado (XXX), el día 23 de agosto de 2013⁴.

5.- En desarrollo de la indagación preliminar, se decretaron y practicaron pruebas documentales, así como testimoniales y luego de aplazarse por el investigado en dos ocasiones la diligencia de versión libre⁵, el funcionario de conocimiento una vez valoradas las pruebas recaudas en el transcurso de la indagación preliminar, citó a audiencia de proceso Verbal Disciplinario al encartado, mediante auto del 14 de febrero de 2014, por considerarlo como presunto autor responsable de la falta disciplinaria Gravísima, prevista en el artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, en concordancia y por remisión normativa con los artículos 287 y 428 del Código Penal, esto es por la presunta falsedad en documento público y el presunto abuso del cargo respectivamente, cometidos por el indagado (XXX) a título de Dolo⁶.

6.- El auto de citación a audiencia y cargos fue notificado personalmente al abogado de confianza del acusado, doctor (XXX), el día 24 de febrero de 2014 y al enjuiciado se notificó subsidiariamente por edicto No. 008-2014 del día 26 de febrero de la misma anualidad⁷.

7.- Llegado el día 17 de marzo de 2014 la primera instancia se constituyó en Audiencia Pública y dio inicio al juicio verbal correspondiente. En esta sesión inicial, realizada en presencia de los sujetos procesales, el disciplinado se abstuvo de rendir versión libre, quien manifestó en dicha oportunidad acogerse al derecho de guardar silencio; Por su parte el abogado defensor solicitó la declaración de nulidad de todo lo actuado hasta la citación o imbricación del proceso ordinario a audiencia verbal, por considerar que no estaban dados los presupuestos ni garantías formales de orden legal para el efecto, en los términos del artículo 175 del CDU, esto es para citar a audiencia de juicio Verbal al disciplinado, así como tampoco estaban en debida forma recepcionadas las declaraciones juramentadas que hasta el momento servían de sustento probatorio para el pliego de cargos, por cuanto considero la defensa que se habían recepcionado bajo las prerrogativas de la ley 600 de 2000, cuyo marco normativo se encontraba derogado por la ley 906 de 2004.

² Ver folio 4 y 5 Cno 1.

³ Ver folios 1 y 2 Oficio No.132000201-0784 del 14 de agosto de 2013, suscrito por la Directora Seccional de Impuestos de Bogotá.

⁴ Ver folio 19 Cno 1.

⁵ Ver folios 100 y 103 Cno 1.

⁶ Ver folios 122 a 131 Cno 1.

⁷ Ver folios 136 a 139 Cno 1.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

8.- De otra parte la defensa solicitó la práctica de la prueba testimonial de la funcionaria de la Dian (XXX), la cual fue decretada por el director de la Audiencia en el transcurso de la misma. En cuanto a la solicitud de nulidad deprecada por la defensa considero el despacho instructor luego de algunas prolijas consideraciones sobre los principios Jurisprudenciales que regentan la figura de la nulidad procesal, que para el sub-examine no se encontraban satisfechos tales preceptos, como para predicar de ello la nulidad del auto de citación a audiencia, ni de las pruebas testimoniales que obran en el plenario⁸, decisión que fue recurrida por la defensa en la misma audiencia y que luego de un breve receso fue decida desfavorable por el despacho de instrucción, manteniendo su posición frente a las argumentaciones anulatorias deprecadas por la defensa.

9.- Siguiendo con el curso del juicio verbal, el día 18 de marzo ogaño se recaudó en audiencia la declaración juramentada decretada a solicitud de la defensa, de la funcionaria de la Dian (XXX), como también se recepcionó la versión libre del disciplinado (XXX) y se presentaron por la defensa de forma verbal y escrita los alegatos de conclusión⁹. Seguidamente por el despacho instructor se decretó un receso de la audiencia para motivar el respectivo fallo.

10.- Llegado el día y hora prefijados se profirió el fallo de primera instancia, a través del cual el despacho A Quo declaró al procesado (XXX), como responsable de cometer la falta disciplinaria objeto de acusación previa en el pliego de cargos. Consecuencia de lo anterior, se impuso como sanción al disciplinado la Destitución e Inhabilidad General por el término de doce (12) años para ocupar cargos y ejercer funciones públicas. Concluida la lectura del fallo, y notificado en estrados a los sujetos procesales, la defensa técnica, a cargo del togado (XXX), interpuso y sustentó el recurso de apelación, razón por la cual fue concedida la impugnación ante la Dirección General de la UAE Agencia ITRC, despacho al que fue remitido el expediente el día 26 de marzo de 2014 para desatar la alzada¹⁰.

11.- Por auto del 1 de abril del año en curso¹¹, este despacho dio aplicación al inciso séptimo del artículo 180 del C. D. U., modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, corriendo traslado a los sujetos procesales, apelantes y no apelantes, por el término común de dos (2) días, para presentar alegatos finales frente al recurso de apelación.

12.- Cumplida la notificación al procesado (XXX) por estado No. 043-2014 del 11 de abril ogaño,¹² y personalmente al abogado defensor el día 9 de abril de esta anualidad¹³, así como surtido el traslado pertinente¹⁴, los sujetos procesales hicieron uso de dicha oportunidad procesal en termino y en idénticos argumentos alegados en el recurso de alzada¹⁵, por lo tanto se recibió nuevamente el expediente en este despacho de segundo grado, para desatar el recurso.

⁸ Ver folios 154 a 158 Cno 1.

⁹ Ver folios 150 a 153 Cno 1.

¹⁰ Ver folios 178 a 181 Cno 1.

¹¹ Ver folios 183 Cno 1.

¹² Ver folio 187

¹³ Ver folio 186

¹⁴ Ver folio 188

¹⁵ Ver folios 189-196

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN IMPUGNADA

Antes de iniciar las consideraciones de primera instancia, el funcionario A Quo resumió en algunos párrafos los hechos objeto de la investigación; el cargo formulado en la Citación a Audiencia; y los argumentos defensivos del procesado, planteados a lo largo del juicio, tanto en su versión libre, como en los alegatos de conclusión. De la misma manera se resumieron valoraron y evaluaron conjuntamente la totalidad de las pruebas documentales y testimoniales recaudadas a lo largo de la actuación, preliminar como del juicio Verbal.

Inmediatamente, la primera instancia inició sus motivaciones citando la normatividad que le atribuye competencia legal para fallar el sub examine. A renglón seguido nombran en el fallo impugnado los preceptos legales que describen, en materia disciplinaria, la exigencia probatoria mínima para sancionar y el sistema de valoración o apreciación integral probatoria.

Consideró el fallador de primera instancia, que con base en el análisis probatorio decretado y practicado legal y oportunamente en el plenario, tanto en la etapa de indagación preliminar como en la etapa de juicio, los cargos que se formularon al investigado dentro del auto de citación a audiencia y cargos, constituyen una imputación diáfana y concreta, de suerte que el disciplinado conto con todas las posibilidades procesales de ejercer sus derechos de contradicción y defensa respecto de la misma, para proceder a decidir como en derecho corresponda.

Continuando con la motivación del fallo, referente a la valoración probatoria estimo el despacho A-Quo, que se encontraba plenamente probada la materialización de las conductas típicas e ilícitamente sustanciales endilgadas en el pliego de cargos al señor (XXX), en cuanto a que de la documental y los testimonios allegados al plenario, en concordancia con la propia versión libre del disciplinado, se pudo establecer que el investigado uso su carné institucional de la Dian, exhibiendo un acto administrativo supuestamente erigido por la entidad y haciendo gala de su posición como funcionario público en horario laboral, visitó a un contribuyente persona natural, sin tener competencia ni delegación para ello y exigió la revisión de los libros contables del establecimiento de comercio, traspasando de esa manera, para el despacho instructor, los límites de sus funciones, fraguando así el abuso de función pública en su calidad de servidor público, y materializando la falsedad de documento público.

Conductas enrostradas por el sensor de primera instancia en el pliego de cargos al expedientado, por cuanto, fabricó un documento con apariencia de legalidad y probidad, para hacerlo parecer una fuente de obligaciones a cargo del contribuyente ilegalmente visitado, quien en un primer momento pensó que el acto administrativo era real y por tal motivo ofreció al funcionario sus libros contables, tal como este se lo había requerido.

Continuando con la exposición de motivos del fallo, argumentó el A Quo el cumplimiento del requisito de la ilicitud sustancial satisfecho, al expresar que la conducta imputada al procesado vulneró su deber funcional, sin justificación alguna, pues en su condición de servidor público debía actuar bajo postulados de moralidad pública, diligencia, eficiencia y eficacia, es decir, a partir de normas rectoras de su ejercicio, tal como lo establece la ley

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

disciplinaria en sus artículos 5 y 22, por cuanto, al asumir su cargo el disciplinado en el año 2006, se comprometió a cumplir con fidelidad y respeto sus deberes funcionales legales, constitucionales y a representar de forma altruista a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales frente a los ciudadanos, situación que considero el despacho instructor que en el sub lite no se cumplió, sino que por el contrario el disciplinado mancilló los principios de transparencia y moralidad de la función pública a los que estaba obligado acatar, sin justificación alguna.

Con relación al requisito estructural normativo de la culpabilidad de la falta, mantuvo el fallador de instancia su posición esbozada en el auto de citación a audiencia, al considerar que la falta objeto de sanción debe ser imputada a título de Dolo, pues evidenció en el actuar del procesado que no existía duda sobre el conocimiento, intencionalidad y ánimo del funcionario (XXX) en su actuar, pues por un lado conocía que no estaba comisionado para visitar al contribuyente y no obstante, a sabiendas de ello, actuó de manera equívoca, construyendo un documento suplantatorio de la voluntad de la Administración de Impuestos Nacionales, falsificación que conlleva un contenido Doloso per sé, aunado a que el tipo penal no comporta en su legislación compuesta, modalidad culposa, sino que refiere implícitamente al conocimiento y voluntad por la manera en que se encuentra enunciado.

En el acápite subsiguiente, titulado Contestación a los argumentos de defensa, el fallador hizo nuevamente énfasis al hecho de que en consonancia con los argumentos expuestos por el procesado en su versión libre, el abogado defensor sugiere que dentro del escrito acusatorio por el que se está juzgando a su prohijado, adolece de atipicidad por cuanto al tenor del artículo 48 numeral 1º del CDU, el reproche disciplinario recaba en que la conducta se realice en razón, con ocasión, como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo, y que tal como se pudo establecer la actuación de su defendido en nada tenía que ver con su cargo ni con los deberes funcionales que se derivan del mismo.

En lo que respecta a la calificación de la falta, el despacho A Quo mantuvo la posición asumida en su auto de llamamiento a juicio y cargos, en consecuencia, califico las conductas imputadas disciplinariamente al funcionario (XXX), como Gravísimas a título de Dolo, al hallarlas enmarcadas en los preceptos normativos del artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002.

En el proceso de dosificación de la sanción, atendiendo a la calificación concreta como Gravísima a título de Dolo imputada al disciplinado y contentiva de la falta del numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en armonía complementaria con los artículos 287 y 428 del código penal, consideró el despacho de primera instancia viable la imposición de la sanción de destitución e inhabilidad general por el termino de doce (12) años al disciplinado (XXX), teniendo en cuenta, en favor del procesado los criterios normativos atenuantes del artículo 47 del CDU, en canto a su ausencia de antecedentes fiscales y disciplinarios; el no haber atribuido infundadamente el hecho a un tercero; la inexistencia de un grave daño social o afectación de derechos fundamentales con la conducta reprochada; y no pertenecer el enjuiciado a un cargo de nivel directivo o ejecutivo de la DIAN.

De otra parte, el despacho de primera instancia tuvo en cuenta en la dosificación de la sanción las prerrogativas del numeral segundo del artículo 47 ibídem, que establece que en

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

aquellos eventos en los que la sanción más grande es la destitución e inhabilidad general, esta última se incrementara hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal, en aquellos eventos en los cuales el disciplinado infrinja varias disposiciones de la Ley Disciplinaria, con una o varias acciones u omisiones, o varias veces la misma disposición.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, esto es, en desarrollo de la misma audiencia de fallo y con la presentación del escrito de alzada, fechado el día 20 de marzo del año en curso¹⁶, el defensor del procesado sustentó su recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio de primera instancia, solicitando de este despacho Ad Quem, la absolución de su cliente, con base en los siguientes planteamientos:

Desde el comienzo de sus alegatos de conclusión como de su escrito de impugnación el abogado apelante planteó la violación del debido proceso de su defendido, por cuanto indico que el procedimiento que se adelantó fue desacertado por el despacho instructor, por cuanto se debió adelantar bajo la cuerda procesal del proceso ordinario y no por el proceso verbal como en efecto ocurrió, generando en su parecer la nulidad de toda la actuación surtida, por considerar que dicho proceso verbal no le permitía a su defendido las garantías procesales de defensa necesarias.

Agrego que dicha solicitud quedo zanjada con la negativa del despacho al desatar el recurso de reposición, dado que contra esa decisión solo procedía tal recurso y en consecuencia rogo a este sensor de instancia valorar nuevamente las alegaciones hechas por la defensa sobre el particular, las cuales reposan en el expediente, pues considero que al haberse proferido un fallo dentro de un procedimiento inadecuado, se vulneraron las garantías procesales del disciplinado.

De otra parte alego la indebida valoración probatoria del fallo A Quo, por cuanto ese despacho le otorgó a las pruebas testimoniales en su entender una vocación probatoria que las mismas no tenían. Al respecto señalo que la argumentación del despacho para sancionar, es que cuando el señor (XXX) desplego la conducta reprochada, lo hizo sin estar comisionado para ello, esto es sin estar ese tipo de actividades dentro del radio de sus funciones y que al identificarse como funcionario de la DIAN, abusó de su cargo.

Agrego que el mismo despacho reconoció que el disciplinado no estaba en ejercicio de sus funciones, pues su cargo no le permitía ejercer la actividad de auditoria a personas naturales, pues la esencia de sus funciones estaba orientada de manera exclusiva a la intervención auditora de investigaciones de personas jurídicas como sujetos pasivos de su actuar como servidor público y no de personas naturales como en efecto ocurrió.

Arguyo el recurrente que por lo anterior queda claro que el investigado no actuó en ejercicio de sus funciones y atribuciones propias del cargo, por ende no podía omitir o extralimitarse en funciones, que de suyo no tenía.

¹⁶ Ver folios 178 a 180 Cno 1.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

Por lo anterior concluye que el disciplinado (XXX) no cometió falta disciplinaria alguna y por más reprochable que sea su actuar, en estricta observancia de la Constitución y de la ley disciplinaria no está llamado a responder disciplinariamente por su actuar, pues su conducta fue autónoma de su fuero interno como particular, y por ello la conducta del disciplinado en su entender es atípica, lo cual deberá reconocerse en el fallo de segunda instancia.

Por ultimo alego la indebida dosificación de la sanción, por cuanto señalo que el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta todos los atenuantes de tipo normativo a favor de su representado, lo que en su entender demuestra una vez más los yerros del fallo de primera instancia.

En síntesis, estos fueron los planteamientos por los cuales el defensor solicitó la absolución de responsabilidad disciplinaria de su prohijado y la terminación del presente proceso disciplinario.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Antes de dar inicio a las consideraciones de instancia, es importante precisar que de conformidad con las previsiones legales consagradas en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, "...El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación..."*sic*.

Sea lo primero advertir que pese a que en el fallo objeto de impugnación se realizó una completa motivación o pronunciamiento frente a cada uno de los argumentos defensivos planteados, avista esta instancia que el escrito de alzada se limitó a hacer una reiteración total de los alegatos de conclusión, sin aportar elementos diferentes de debate, destinados a desvirtuar de fondo la posición del A Quo, para finalmente presentar una nueva tesis, frente a la cual el fallador de segundo grado pueda decidir cuál de los dos postulados se ajusta a derecho y en consecuencia dirimir el conflicto jurídico planteado.

Sobre el particular es necesario traer algunas tesis jurisprudenciales sobre la forma debida en que debe ejercerse el derecho adjetivo de impugnación:

Al respecto La H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal, en auto del 11 de septiembre de 1984 puntualizó:

"...No constituye, por tanto, sustentación adecuada, el empleo de frases o expresiones en las cuales simplemente se manifiesta un desacuerdo genérico, pero no se indican en concreto los aspectos que deben ser reformados o revocados por el superior, ni tampoco estará cabal ni debidamente sustentado el recurso que carezca de las razones, de tipo probatorio o jurídico que deben llevar a dicha reforma o revocatoria..."

Para entender más esta postura jurisprudencial, la misma Corte Suprema precisó:

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

“...Si la apelación es una faceta del derecho a impugnar, expresión ésta derivada de la voz latina impugnare, que significa “combatir, contradecir, refutar”, tiene que aceptarse que el deber de sustentar un recurso consiste precisa y claramente en dar o explicar la razón o motivo concreto que se ha tenido para interponer el recurso; o sea, para expresar la idea con criterio tautológico, presentar el escrito por el cual mediante la pertinencia crítica jurídica, se acusa la providencia recurrida a fin de hacer su contrariedad con el derecho y alcanzar por ende su revocatoria o modificación...”(ejusdem).

Al respecto agregó la Alta corporación:

“...Para no tolerar esguinces al precepto legal citado, y más precisamente para impedir que su razón finalística se quede en la utopía, cree la Corte que no pueda darse por sustentada una apelación, ni por ende cumplida la condición que subordina la admisibilidad de este recurso, cuando el impugnante se limita simplemente a calificar la providencia recurrida de ilegal, injusta o irregular; tampoco cuando emplea expresiones abstractas tales como “si hay prueba de los hechos”, “no están demostrados los hechos”, u otras semejantes, puesto que aquellos calificativos y expresiones, justamente por su vaguedad e imprecisión no expresan, ni siquiera implícitamente, las razones o motivos precisos de la inconformidad del apelante con las deducciones lógico-jurídicas a que llegó el juez de instancia en su proveído impugnado”(Sala Penal Auto de agosto 30/84)...”.

Sin embargo a las anteriores precisiones sobre el recurso de alzada y en aras de garantizar plenamente el derecho de defensa y contradicción propios de la impugnación, pasará este despacho de segunda instancia a considerar y evaluar punto por punto del recurso.

En primer término y frente a la alegada violación del debido proceso del disciplinado, por no haberse tramitado el proceso de primera instancia, por la cuerda procesal del procedimiento ordinario, de otra parte por la presunta indebida valoración probatoria en cuanto al alcance verdadero de estas, frente al tipo conductual disciplinario endilgado y por ultimo frente a la indebida dosificación de la sanción apelada, por cuanto al parecer del recurrente el fallador de primera instancia, no tuvo en cuenta todos los atenuantes del tipo normativo en favor de su representado.

DEL DEBIDO PROCESO Y DEL DERECHO DE DEFENSA

Argumentó la defensa en su escrito de impugnación que la solicitud de nulidad del proceso por violación del mismo ya había quedado zanjada con la negativa del despacho al desatar el recurso de reposición, dado que contra esa decisión solo procedía tal recurso, sin embargo rogo a este sensor de instancia valorar y verificar nuevamente las alegaciones hechas por la defensa sobre el particular, pues consideró que al haberse proferido un fallo dentro de un procedimiento inadecuado, se vulneraron todas las garantías procesales de su prohijado.

Indica el recurrente, que se violó el debido proceso en primera instancia al disciplinado (XXX), al no haberse tramitado el procediendo pertinente al caso concreto, como en su parecer lo sería por el procedimiento ordinario y no por el proceso verbal como en efecto ocurrió, por cuanto señaló que no existían los requisitos mínimos legales que permitieran soportar el auto de citación a audiencia y cargos, para imbricar el proceso de ordinario a

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

verbal, a la luz de los preceptos legales consagrados en el artículo 175 del CDU., y porque en el sub –examine no hubo flagrancia, para justificar la aplicación de un proceso verbal como lo exige el mismo artículo 175 citado, en concordancia con el artículo 301 de la ley 906 de 2004, pues manifiesta el inconforme que pasaron más de seis meses desde la apertura de la indagación preliminar hasta el auto de citación a audiencia, razón por la cual no podía hablarse por el despacho A-Quo de flagrancia para citar a audiencia como requisito sine quantum, para la imbricación del proceso ordinario a verbal.

Previo a analizarse por este despacho Ad-Quem el fondo del anterior alegato, ha de recordarse que el artículo 175 de la ley 734 de 2002 señala los escenarios facticos como procesales y de orden probatorio, para que el instructor disciplinario de aplicación al procedimiento Verbal.

Reza el articulado:

“...El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve...”.

“...También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 de esta ley...”.

“...En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia...”. (Subrayas fuera de texto).

Corolario de lo anterior es importante destacar que es el mismo contenido del inciso final del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, el que prescribe claramente que en todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación, - es decir en la etapa de indagación preliminar - se encuentran dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia.

A su turno los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se encuentran señalados en el artículo 162 ibídem, así:

(...)El funcionario de conocimiento formulará Pliego de Cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado (...) (subrayas fuera de texto).

Por lo anterior encuentra este despacho que en concordancia y plena subvención de la norma referida y de conformidad con las pruebas legal y oportunamente valoradas y allegadas al plenario por el despacho a-quo,

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

los dos requisitos normativos arriba señalados para citar a audiencia, se encontraban plenamente satisfechos al momento de proferirse el auto de citación a audiencia No.17412-023 del 14 de febrero de 2014 objeto de impugnación, esto es, que se encontraba objetivamente probada la falta por la cual se inició la indagación preliminar y que existía prueba fehaciente que comprometía para ese momento procesal la responsabilidad del disciplinado, lo anterior atendiendo al oficio No. 0132000201-0784 del 14 de agosto de 2013, suscrito por la Directora Seccional de Impuestos de Bogotá, en el cual informó las presuntas irregularidades del **acto administrativo referido** y presumiblemente delegado al aquí disciplinado (XXX), para adelantar la actuación administrativa, objeto de reproche en el auto de citación a audiencia¹⁷.

Nótese que del relató nada reticente del informe presentado ante la agencia ITRC por la Directora Seccional de Impuestos de Bogotá¹⁸, se establece que horas más tarde se recibió una llamada telefónica en el despacho de dicha Seccional, en el que se informó que la policía había capturado a la persona que se presentó con el auto comisorio en dicho establecimiento de comercio y que se encontraba siendo trasladado a la URI de Paloquemao, así mismo que se trataba del funcionario de la DIAN, (XXX).

En desarrollo de la indagación preliminar, se decretaron y practicaron suficientes pruebas documentales, así como testimoniales¹⁹ por el despacho de instrucción para corroborar los hechos del anterior informe y luego de aplazarse en dos ocasiones en dicha etapa por el investigado la diligencia de versión libre, el funcionario de conocimiento una vez valoradas conjuntamente las pruebas recaudas en el transcurso de la indagación preliminar, citó a audiencia de proceso Verbal Disciplinario al encartado, mediante auto del 14 de febrero de 2014, por considerarlo como presunto autor responsable de la falta disciplinaria gravísima, prevista en el artículo 48, numeral 1º de la Ley 734 de 2002, en concordancia y por remisión con los artículos 287 y 428 del Código Penal, esto es por la presunta falsedad en documento público y el presunto abuso del cargo respectivamente, cometidos por el disciplinado a título de Dolo.

Razón por la cual estima este despacho de segunda instancia, atendiendo las normas transcritas y los por menores procesales de la actuación surtida en la etapa de indagación preliminar por el despacho A-quo objeto de análisis,²⁰ que en efecto existían suficientes elementos de juicio tanto facticos, como probatorios para citar a audiencia al señor (XXX), atendiendo a sí mismo a la etapa procesal pertinente que por disposición del inciso final del artículo 175 del CDU como arriba se indicó, establece que si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación, - es decir en la etapa de indagación preliminar- se encuentran dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, entonces se citará a audiencia, como en efecto ocurrió en el caso concreto, del auto de citación a audiencia del 14 de febrero de 2014.

¹⁷ Ver folios

¹⁸ Ver folios 1 a 3 Cno 1.

¹⁹ Ver folio 124 a 127 del Cno 1.

²⁰ “En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos se citará a audiencia” art.175 CDU.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

Es preciso indicar que la providencia de citación a audiencia, la cual equivale al pliego de cargos, es una imputación o acusación formal, de carácter provisional y que posibilitaba al disciplinado ejercer sus derechos de contradicción y defensa respecto de una o varias conductas en concreto endilgadas. En tal circunstancia, las expresiones y el lenguaje empleado en la redacción del proveído fue a título de “presuntos los hechos imputados, las normas violadas y, ante todo, la responsabilidad del disciplinado”, lo que de suyo tampoco frente a este aspecto le violó el debido proceso y la presunción de inocencia al disciplinado, alegada por la defensa.

En lo que respecta al caso sub examine hay que recordar que el investigador disciplinario disponía al momento de valorar las pruebas y los hechos para citar a audiencia, de un amplio campo y autonomía legal para determinar si la conducta investigada se subsumía o no en los supuestos de hecho de los tipos legales correspondientes, y si esta fue cometida con dolo o con culpa, lo mismo que su mayor o menor grado de gravedad, con base en los criterios señalados en los Art. 13 y 43 del CDU.

Con base en lo anterior, es de anotar como peculiaridad propia del derecho disciplinario, la posibilidad de que las conductas constitutivas de faltas disciplinarias se encuadren en la forma de “tipos abiertos”. A diferencia de la materia penal, en donde la descripción de los hechos punibles es exhaustiva y detallada, en la disciplinaria el fallador ha reconocido la jurisprudencia que cuenta con un mayor margen de valoración e individualización de las faltas sancionables por la diversidad de comportamientos que pugnan contra los propósitos de la función pública y del régimen disciplinario²¹.

A este respecto se ha pronunciado la H. Corte Constitucional al precisar:

“(…)La prohibición de la conducta delictiva involucra un conjunto de patrones que establecen una precisión tipológica en la que se describen de manera detallada los elementos conformantes del tipo, de manera que, sujeto activo, conducta, intención, sujeto pasivo y circunstancias llevan en el procedimiento penal a una exhaustiva delimitación legal de las conductas; mientras que en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación, tal como lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(…) (Subrayas fuera de texto).

Sobre el particular la H. Corte Constitucional se pronunció más recientemente en sentencia C-242 de 2010 sobre el requisito *sine quantum* para citar a audiencia de juicio verbal en el proceso disciplinario, con base en las pruebas que obren en el expediente:

(…) El elemento común a todo el conjunto de faltas respecto de las cuales se debe aplicar el proceso verbal es el aspecto probatorio, esto es, que su característica principal consiste en tratarse de conductas que al momento de valorar sobre la

²¹ Ver sentencia C-242 de 2010

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

decisión de apertura de investigación, estén dados los requisitos para proferir pliego de cargos y citar a audiencia (...) (Subrayas fuera de texto).

De las anteriores líneas jurisprudenciales se colige claramente que el instructor disciplinario de primera instancia no solo gozaba de un amplio margen de valoración probatoria y fáctica sobre las pruebas que había recaudado en la etapa de indagación preliminar, para citar a audiencia de proceso verbal al expedientado (XXX), sino que como se desprende de una lectura sistemática y armónica del auto de citación a audiencia cuestionado, la flagrancia del disciplinado referida en la mentada providencia, solo se predica como uno de los demás requisitos procesales y no acumulables para citar a audiencia, establecidos en el artículo 175 del CDU; que en el presente caso probado esta que sucedieron en referencia a la captura en flagrancia del disciplinado el día 12 de agosto de 2013, pero que en nada sustentan el fondo de la decisión de citación a

Comparte este despacho la exposición de motivos de la decisión que resolvió en su momento el recurso horizontal el despacho A-Quo al libelista, en cuanto le puso de presente que su decisión de citación a audiencia, se basaba en la valoración previa y conjunta de las pruebas legal y oportunamente allegadas en la etapa de indagación preliminar y no como lo interpreto el recurrente, por la desacertada interpretación de una presunta flagrancia motivadora de la decisión de imbricación de proceso ordinario a juicio verbal.

En lo que respecta al procedimiento de Juicio Verbal adelantado en el sub-examine, encuentra este sensor de instancia que en efecto se atendieron a cabalidad las reglas jurídicas que gobiernan esta clase de actuaciones procesales administrativas, sin descuidar etapa procesal alguna, cumpliéndose así con el fin para el cual han sido instituidas cada una de ellas.

Recuérdese que la H. Corte Constitucional ya ha analizado en varias oportunidades la constitucionalidad de los procesos verbales y ha determinado que los procedimientos disciplinarios verbales son Constitucionales y desarrollan a plenitud todos los principios procesales y administrativos consustanciales de la funcione publica, referentes a la celeridad, eficacia, economía procesal, inmediación y concentración de las audiencias y oralidad, siendo las principales características del procedimiento verbal de responsabilidad disciplinaria, contemplado en las disposiciones reglamentarias del artículo 175 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 29 y 209 Superiores.

Para la H. Corte Constitucional, el procedimiento verbal garantiza una mayor eficiencia y celeridad al proceso disciplinario, en la medida en que permite un desarrollo más ágil a los casos contemplados en la ley. Esto le da fortaleza y equilibrio al proceso porque permite que el proceso termine en un periodo más corto, dando mayor credibilidad a la administración de justicia.

Parafraseando al tratadista Davis Echandía, al referirse al proceso verbal indico que, “*debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo de actividad procesal*”, esto se cumple aplicando el principio de la economía procesal. Específicamente el proceso verbal

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

disciplinario, tiene como principios fundantes la publicidad, la concentración, la celeridad, la eficiencia, la inmediación, la contradicción y la economía procesal²².

Al respecto en sentencia C-370/12 enfatizo el Alto Tribunal Constitucional:

(...)La celeridad, si bien se aplica para las situaciones establecidas expresamente en la ley, todas las etapas del proceso verbal se surten en el trámite de la audiencia, los términos son breves, las intervenciones de los sujetos procesales se recogen en medio magnético y sólo se levanta un acta con un resumen sucinto de las actuaciones. Los sujetos procesales cuentan con una gama de garantías que devienen del debido proceso constitucional, pues conocen previamente la acusación, se les concede un término para presentar descargos, pueden solicitar pruebas y se encuentran habilitados para interponer recursos (...).

(...)Asimismo, a partir de ese momento, se generan todas las garantías propias del debido proceso verbal, dentro de las cuales se encuentran: (i) la notificación personal del auto que ordena adelantar el proceso verbal y de la citación a audiencia; (ii) la realización de la versión libre propia de los hechos y de solicitar y aportar pruebas; (iii) la presentación de alegatos de conclusión y la posibilidad de solicitar un receso para elaborar los mismos; y (iv) la posibilidad de interposición de recursos contra las decisiones que niegan la práctica de pruebas, las nulidades y la recusación, así como también contra el fallo de primera instancia(...).

De las anteriores consideraciones puede concluirse entonces, que el propósito de buscar la celeridad del proceso disciplinario verbal es una finalidad Constitucionalmente Importante, porque con ello se materializan los principios que regentan el ejercicio de la función pública, como lo son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (C.P. art. 209) y resultan consistentes con los objetivos que buscó obtener la Ley 734 de 2002.

De acuerdo con las normas legales que rigen esta clase de actuaciones administrativas sancionadoras, establece este despacho que en el presente caso se cumplió a cabalidad con las respectivas etapas del debido proceso disciplinario, pues, como se aprecia claramente, el inculpado conoció con antelación los cargos endilgados, presentó sus respectivos descargos y alegatos de conclusión y oportunamente controvertió las pruebas allegadas en su contra. Además, al proceso se le imprimió el principio de la doble instancia, que con esta providencia y una vez ejecutoriada quedara surtido.

Finalmente y sobre el particular si alguna irregularidad se presentó dentro de la respectiva actuación administrativa procesal disciplinaria Verbal de primera instancia, la cual no se advierte, ha debido entonces el interesado demostrar tal inconsistencia, respecto de la supuesta violación del debido proceso, que a juicio de este despacho, se itera, no existió.

²² Sentencia C-401 de 2013

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

DE LA VALORACIÓN PROBATORIA

Como lo ha reconocido el H. Consejo de Estado en otras oportunidades²³, el debido proceso es una garantía Constitucional instituida en favor de las partes y de aquellos terceros interesados en una determinada actuación administrativa o judicial (artículo 29). Consistente en que toda persona - natural o jurídica - debe juzgarse conforme a las leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándosele siempre y para el efecto, principios como los de publicidad y contradicción, y el derecho de defensa.

En el caso examinado, y según las pruebas que obran dentro del proceso, la actuación administrativa disciplinaria se surtió con plena observancia de las normas preexistentes y aplicables a la situación particular del impugnante, atendida la vigencia y obligatoriedad de las mismas.

Sobre el particular alega la defensa que lo irregular es que la argumentación sobre la valoración probatoria obrante en el expediente que realiza el despacho A-quo, consiste en que cuando el señor (XXX) desplego la conducta que dio como resultado el fallo sancionatorio que hoy se impugna, lo hizo "sin estar comisionado para ello", "sin estar en función de ese tipo de actividades"²⁴ dentro de las atribuciones propias de su cargo "pues indica que al identificarse como funcionario de la Dian, no abusó de su cargo" e insiste en que el despacho instructor a través de toda su intervención reconoció que su procurado no estaba en ejercicio de sus funciones, pues su cargo no le permitía ejercer la actividad de auditoria a personas naturales, pues la esencia de sus funciones estaba orientada de manera exclusiva a la intervención auditora e investigativa de personas jurídicas, como sujetos pasivos de su actuar como servidor público. Por ultimo pregunta la defensa *¿Cómo puede alguien abusar de un cargo que no tiene?* Y se contesta de la siguiente manera: *"La respuesta además de lógica es simple y evidente: de ninguna manera!"... sic.*

Concluye señalando que no está llamado a responder disciplinariamente el disciplinado (XXX), pues su actuar fue autónomo de su fuero interno como particular y no tenía funciones, competencias ni atribuciones para realizar la actividad por la que fue sancionado en primera instancia, requisito sine quantum, para ser sujeto pasivo de la ley disciplinaria. Por tanto señala que la conducta del disciplinado es atípica y así deberá declararse en al presente providencia.

A juicio de esta Segunda Instancia, las exculpaciones ofrecidas por el recurrente para salvaguardar la responsabilidad disciplinaria de su prohijado, no resultan atendibles. En efecto, es claro para este despacho que el señor (XXX), en su condición de funcionario técnico de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá del Git de Control a Obligaciones Formales de la División de Fiscalización de Personas Jurídicas, de la UAE Dian, materializó tal como lo analizó el despacho A-Quo, la descripción conductual del artículo 428 del Código Penal, esto es por realizar funciones diversas y distintas de su cargo, pero en ejercicio del mismo, es decir abusó del cargo en el horario laboral, lo que para este despacho en el sub-examine, efectivamente ocurrió, por cuanto si bien, y tal como lo hace ver la defensa, dentro

²³ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección segunda -subsección "B" Consejero Ponente: Tarsicio Cáceres Toro Bogotá, D.C., Octubre 31 2002.

²⁴ Ver folio 178.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

de las funciones del disciplinado, se encontraban las de efectuar visitas a los contribuyentes, lo cierto es que estas actuaciones se realizaban en ambos grupos de obligaciones formales, tanto de contribuyentes personas jurídicas, como contribuyentes personas naturales.

De otra parte a juicio de este despacho acierta el A-quo, al señalar en el fallo de primera instancia que las facultades funcionales del investigado, no son indiscriminadas ni discrecionales, en cuanto a la delegación o comisión de sus funciones, sino que las mismas deben estar amparadas previamente en un auto comisorio debidamente expedido por el respectivo Jefe de grupo y con la premisa de que sobre el contribuyente a investigar exista una actuación tributaria previa y en curso, premisas que comparte la segunda instancia con la primera, en cuanto a que no se cometieron, ni se establece en el plenario prueba de lo contrario, ni en el actuar del disciplinado, ni en la exposición de motivos de la defensa.

Téngase en cuenta que adicionalmente y de manera autónoma el disciplinado se denominó como integrante del grupo de fiscalización de personas naturales, situación que se contradice con el extracto de historia laboral allegado al expediente que lo ubica de manera contraria en el grupo de personas Jurídicas, es decir, que su competencia se encontraba limitada a ese tipo de entidades.

Tampoco resulta efectiva la defensa, en cuanto alegó que el funcionario procesado no rebasó los límites de su función fiscalizadora, por cuanto esta encuentra sus límites en la misma norma tributaria en su artículo 688, que obliga a que el funcionario este comisionado por el jefe que tiene dicha función; por cuanto es precisamente ese abuso de conducta sin estar delegado para ella, la que materializó la extralimitación y el abuso de sus funciones, que en el fallo de primera instancia, se enrostró al disciplinado.

En consecuencia se tiene entonces que el funcionario (XXX) realizó funciones diversas y distintas a las asignadas para su cargo o función en horario laboral, sin las formalidades propias de la delegación para ello, desbordando así las facultades derivadas de su cargo, desempeñando funciones distintas a las que le otorgaba la ley y el reglamento, por cuanto el funcionario conocía plenamente no estar comisionado para realizar dicha visita máxime cuando en la planilla radicadora de visitas del grupo interno de trabajo figura que debía acompañar a la señora (XXX) a visitar la empresa (XXX), lo anterior apoyado en la propia declaración de la funcionaria (XXX) ²⁵, lo que quedó en evidencia, por cuanto relató en su jurada, como de manera autónoma ambos funcionarios decidieron realizar labores diversas de las que se les habían encomendado, tal y como lo describe en el mentado correo dirigido al jefe de la División, donde explicó el por qué no se efectuó la visita al señalado contribuyente, lo cual corrobora más tarde el propio disciplinado en su versión libre, en desarrollo de la audiencia del 18 de marzo de 2014.

Por otra parte si se aceptara en gracia de discusión por este sensor de instancia que en efecto el funcionario (XXX) no se encontraba en ejercicio de sus funciones al efectuar las conductas reprochadas, se estaría en desconocimiento del propio artículo 6 de la Constitución Nacional que impone a los funcionarios públicos responsabilidades no solo por el incumplimiento de la ley, sino por la omisión o la extralimitación de sus funciones,

²⁵ Diligencia recepcionada en audiencia del 18 de marzo de 2014 folios 160-161.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

entendida dicha extralimitación en el ámbito penal y en advenimiento normativo al derecho disciplinario, como el hecho de que el servidor público desborde las facultades propias de su cargo, asumiendo o desempeñando funciones diferentes a las otorgadas por la ley o el reglamento²⁶, así como también se desconocerían las premisas del artículo 121 de la Carta Política cuando establece que “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”, seguido del artículo 122 al preceptuar que “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o el reglamento”.(Subrayas del despacho).

Estas normas de orden Superior conllevan a la conclusión diáfana, que a fin de evitar la arbitrariedad de los servidores públicos,(desmanes, usurpación de funciones y/o abusos de las mismas), dentro de nuestro Estado existe una rigurosa asignación de funciones, las cuales se erigen bajo presupuestos Constitucionales y legales del Estado de Derecho, en la medida en que todas las autoridades encuentran una estricta misión y destinación de funciones, las cuales no les es permitido ni desbordar y mucho menos usurpar, so pena de incurrir en infracciones severas a la ley.²⁷

Lo que para el caso concreto claramente sucedió al presentarse el señor (XXX) en un establecimiento de persona natural, contribuyente objeto de la irregular visita, el día 12 de agosto de 2013, identificándose como funcionario de la Dian, manifestándole clara y expresa su voluntad al contribuyente (XXX), que en ejercicio de sus aparentes facultades funcionales como funcionario de la Dian, debía revisar los libros contables del establecimiento, como en consecuencia así sucedió, por cuanto en efecto el disciplinado los reviso sin estar delegado ni facultado para ello, pero haciendo gala de su posición de funcionario público, en horario laboral, para hacerle creer al contribuyente que si lo estaba, a través de engaños al exhibir documentos mendaces e ideológicamente falsos, como lo es del caso el auto comisorio No.32-241-418-2013-091653 del 5 de agosto de 2013.

Lo anterior, demuestra que el procesado (XXX), tampoco justificó sus acciones para la época de los hechos objeto de investigación, incumpliendo así con sus deberes funcionales como servidor público²⁸.

De la apreciación integral sistemática y armónica de las pruebas documentales y testimoniales que obran a folios 123 a 129 del auto de citación a audiencia, como de las valoraciones probatorias que realiza el despacho a-quo en el fallo de primera instancia visibles a folios 165 a 170, resulta evidente que se hicieron por el funcionario disciplinante dentro del ámbito de su autonomía y competencias, así mismo el hecho de que tal valoración no beneficie al recurrente, en nada tiene que ver con la violación al debido proceso y al derecho de defensa alegados.

Al respecto de la valoración probatoria ha puntualizado el H. Consejo de Estado:

²⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, MP Carlos Eduardo mejía Escobar, Sentencia de julio 22 de 1998, expediente de única instancia No. 6989.

²⁷ Ibídem.

²⁸ Art 5 y 22 del CDU.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

(...) Vale la pena precisar que en el ámbito de los procesos disciplinarios no existe una tarifa legal probatoria; de hecho el propio Código Disciplinario Único consagra, en su artículo 131, el principio de libertad probatoria, al establecer que “la falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”. De manera que no es aceptable exigir que se haya recaudado un tipo determinado de pruebas –por ejemplo un testimonio o un documento- para efectos de sustentar un fallo disciplinario, que puede estar basado, por decisión expresa del Legislador, en cualquiera de los medios probatorios admitidos por el sistema legal Colombiano e incluso en otros medios probatorios, como se deduce del mismo artículo 130 ibídem²⁹ (...).

En ese orden de ideas, para la segunda instancia, el criterio de interpretación, valoración y aplicación normativa y probatoria que realizó el despacho A-quo, como órgano de control disciplinario de primera instancia, al que la ley le ha dotado de amplia autonomía e independencia, se ajustó con plena subvención al ordenamiento jurídico, la sanción se impuso sin menoscabo del derecho al debido proceso del disciplinado (XXX), luego de hallar plenamente acreditadas: la comisión de la falta gravísima (art. 48.1 CDU- art 287 y 428 del CP), la ilicitud sustancial de la conducta, (art 5º y 22 CDU) y la responsabilidad subjetiva del actor (Art 13 y 42 CDU), con pruebas legalmente practicadas, y debidamente valoradas, (Art 128 y 130 CDU), como arriba se expuso con suficiencia.

Recuérdese que el funcionario titular de la acción disciplinaria, dada la autonomía e independencia del ejercicio de la autoridad que ejerce, puede hacer uso de las reglas de interpretación de las normas jurídicas como del acervo probatorio recaudado en el curso de la actuación disciplinaria, actuando dentro de los límites impuestos por la Constitución y la ley, dentro del criterio de Autonomía Funcional, que el mismo legislador le ha autorizado y reconocido³⁰.

Así mismo la Jurisprudencia Administrativa como Constitucional³¹ más recientes, han reconocido la interpretación y aplicación de la ley, como un pleno ejercicio propio de la autonomía funcionalmente conferida al servidor que tiene el poder disciplinario; entonces cuando éste adopta las decisiones interpretando y aplicando la ley, siguiendo su propio criterio, y con fundamento en los elementos de juicio y probatorios aportados al proceso, el control de legalidad del acto sancionador no autoriza per sé, la imposición de un criterio de interpretación y valoración diferente; ello sólo es posible en los casos en los que la decisión desborde los límites que imponen la Constitución y la ley³².

En consecuencia, las diferencias interpretativas entre lo expuesto en la decisión disciplinaria por parte del titular de la misma y la interpretación que adopte el procesado frente a los mismos asuntos probatorios, no constituyen por sí mismas razones suficientes para invalidar

²⁹ Consejo De Estado Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente: DR. Gerardo Arenas Monsalve Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil doce (2012) Ref.: Expediente No. 11001-03-25-000-2005-00012-2011.

³⁰ Consejo De Estado Sala Plena De Lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente: DR. Gerardo Arenas Monsalve Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil doce (2012) Ref.: Expediente No. 11001-03-25-000-2005-00012-2011.

³¹ Sentencia C- 1076 de 2002.

³² Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de agosto 8 de 1996. Mag. Ponente: Javier Díaz Bueno. Actor: Alba D. Calderón Parra.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

la decisión administrativa de primera instancia, así, el hecho que tal valoración no beneficie al recurrente, nada tiene que ver con la violación al debido proceso y al derecho de defensa.

La Jurisprudencia de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado³³ ha sido enfática en reconocer en desarrollo del principio de la Autonomía Funcional del Juez Disciplinario, que mientras la valoración fáctica y probatoria que este realice, se encuentre debidamente fundamentada y argumentada en el acto disciplinario sancionatorio o absolutorio, según sea el caso, y la interpretación sea razonable, acorde con las normas legales disciplinarias, las pruebas legal y oportunamente allegadas al plenario y compatibles con la Constitución, la decisión de instancia deberá mantenerse.

DE LA DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN

De otra parte y en cuanto a la presunta indebida dosificación de la sanción argüida por la defensa, encuentra este despacho que las decisiones se adoptaron luego de la valoración integral y en conjunto de las pruebas arimadas a la actuación, bajo una crítica razonada y proporcionada, respetando el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción del encartado, por cuanto en el caso concreto, en el acápite de la sanción a imponer del fallo impugnado, se realizó por el despacho a-quo un esmerado análisis de los criterios valorativos para tal efecto previstos en el Artículo 47 de la Ley 734 de 2002³⁴, motivando la sanción a imponer en consideración a que el mentado artículo establece que en aquellos eventos en los cuales el disciplinado infrinja varias disposiciones de la Ley Disciplinaria, con una o varias acciones u omisiones, o varias veces la misma disposición, como en efecto ocurrió en el sub-examine³⁵, la sanción deberá graduarse de conformidad con lo dispuesto en los literales subsiguientes.

Al respecto señalo el despacho A-Quo: “En el sub examine se predica un concurso de conductas, razón por la cual el despacho de primera instancia aplicará el numeral 2, literal “a” del referido artículo, el cual dispone”:

³³La Sección Segunda, al respecto ha señalado: “Todo lo anterior implica que en sede judicial, el debate discurre en torno a la protección de las garantías básicas, cuando quiera que el proceso disciplinario mismo ha fracasado en esa tarea, es decir, cuando el trámite impreso a la actividad correccional resulta intolerable frente a los valores constitucionales más preciados, como el debido proceso, el derecho de defensa, la competencia del funcionario y de modo singular, si el decreto y la práctica de las pruebas se hizo atendiendo estrictamente las reglas señaladas en la Constitución y en la Ley. A pesar de lo dicho, no cualquier defecto procesal está llamado a quebrar la presunción de legalidad que ampara a los actos de la Administración, pues la actuación disciplinaria debe adelantarse con estricta sujeción a las normas que la regulan, las cuales están inspiradas en las garantías constitucionales básicas.

En ese sentido, si de manera general los actos de la administración están dotados de la presunción de legalidad, esa presunción asume un carácter más valioso en el juicio disciplinario, en el cual el afectado participa de modo activo en la construcción de la decisión, mediante el ejercicio directo del control de la actividad de la administración, cuando ella se expresa en su fase represiva. Dicho en breve, es propio de la actividad disciplinaria, que el control de las garantías sea la preocupación central del proceso correccional. Por ello, cuando el asunto se traslada y emerge el momento del control judicial en sede Contencioso Administrativa, no cualquier alegato puede plantearse, ni cualquier defecto menor puede erosionar el fallo disciplinario.” (Sentencia de 18 de agosto de 2011. Mag. Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Ex. No.250002325000200700753 01.-No. Interno: 0532-2008). En este sentido, en la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B, de fecha 4 de septiembre de 2008, M.P.: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, se confirmó la decisión de primera instancia mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, al encontrar demostrado que: “El auto que ordenó la apertura de investigación omitió ordenar, si a ello había lugar, las pruebas consideradas conducente, tal como dispone el artículo 144, numeral 2°, de la Ley 200 de 1995, es decir que no se trata como parece creer el recurrente de omitir o no la práctica de ciertas y determinadas pruebas, cuya incidencia en una decisión podía no ser determinante, sino de disponer la práctica de todas las que pudieran servir para soportar un Auto de Cargos y frente a las cuales el señor Iván Arias Gómez hubiese podido ejercer su derecho de defensa”.

³⁴ Ver folios 174 y 175 Cno 1.

³⁵ Falsedad Ideológica En Documento Público y Abuso De Función Pública (art 287 y 428 del CP).

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

"...Si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta última se incrementará hasta en otro tanto, sin exceder el máximo legal...";

En consecuencia el despacho a-quo señalo que en razón a que el disciplinado infringió varias disposiciones de la ley Penal y disciplinaria, le impuso como sanción principal la Destitución e Inhabilidad General por el término de doce (12) años.

Visto que el propósito del derecho disciplinario es garantizar la buena marcha de la función pública, mediante la investigación y la eventual sanción de comportamientos que resulten nocivos para los fines y el buen desempeño de las entidades estatales, también corresponde al operador disciplinario evaluar y tasar mediante criterios objetivos y ponderados que respondan a la proporcionalidad y a la dignidad humana, en una sanción ajustada a derecho.

En el caso que ocupa la atención de este Despacho, tal y como quedó expuesto en el ejercicio de valoración jurídica y probatoria en el fallo a-quo, se concluye que la responsabilidad del señor (XXX) por las conductas tipificadas como Gravísimas a la luz del artículo 48 numeral 1, con remisión normativa al Código Penal por los delitos de Falsedad en Documento Público y Abuso de Función Pública, cuyo quantum en esta oportunidad se determinó según los parámetros del Código Disciplinario Único y así, como se advirtió, toda falta Gravísima Dolosa, acarrea de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 citado, que la sanción a imponer sea la de Destitución e Inhabilidad General.

En ese orden de ideas, sobre la materialidad de la conducta asumida por el enjuiciado y sancionada en el fallo de primera instancia, no existe duda para este despacho, que la misma se encuentra ajustada a derecho y proporcional a los hechos imputados en la sanción impuesta por la Sub Dirección Técnica Disciplinaria de la Agencia ITRC. Por lo anterior el cargo impugnado tampoco prospera.

Sin lugar a dudas y a manera de conclusión resulta censurable Disciplinariamente la conducta asumida por el señor (XXX), por cuanto no sólo afectó la imagen de la institución para la cual fue vinculado a laborar mediante precisas Relaciones Especiales de Sujeción, como lo es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a cuyos funcionarios por demás se les exige en los términos de la ley Tributaria y Aduanera, un alto nivel de transparencia y probidad en todas sus actuaciones³⁶, dada la naturaleza misma de su función como entes recaudadores de los Tributos y Rentas en favor del Estado, sino que al no prodigar su actuar el disciplinado en estrictez con la ley y el reglamento, en cuanto a falsificar documentos públicos y usarlos en pleno desborde de sus funciones, resulta por demás reprochable y legalmente trascendental a la comunidad contribuyente, que demandan un actuar recto y transparente de sus funcionarios públicos. Lo anterior le permitió al disciplinado alejarse de los postulados que orientan el ejercicio de la Función

³⁶ **Funcionarios Públicos De La Dian-Exigencia de comportamiento que no riña con la dignidad del Cargo (...)** Sin que ello signifique desconocimiento alguno a los derechos que como personas tienen los funcionarios públicos a una actividad exclusiva de la esfera jurídica-particular, es claro que en atención a la investidura que ostentan, el Estado legítimamente puede exigirles un comportamiento individual externo y público que no riña con la dignidad propia de su carácter de servidores del Estado(...) Sentencia C-725/00.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

Pública, relacionados con la Moralidad Pública y la Pulcritud en todas las actuaciones de la Administración³⁷.

Aquel comportamiento que la parte recurrente en su escrito de impugnación califica como una atipicidad, no obstante para este sensor de instancia encuadra diáfananamente dentro de la descripción conductual de la falta disciplinaria prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la ley 734 de 2002, en la medida en que se encontró probado a lo largo del proceso, que el disciplinado prodigó con remisión al Código Penal en sus artículos 287 y 428, la falsedad en documento público del auto comisorio No.32-241-418-2013-091653 del 5 de agosto de 2013 y el abuso del cargo al usurpar funciones que no le competían ni en la ley, ni en el reglamento.

Las conductas típicas e ilícitamente sustanciales enrostradas en el fallo impugnado al disciplinado (XXX), las encuentra este despacho proporcionadas y legalmente motivadas con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, en cuanto a que tales conductas trascendieron la esfera de lo personal para invadir el ámbito institucional, perturbando el recto y normal funcionamiento del servicio público a cargo de la Dian, materializado a través de sus agentes³⁸.

Desde este momento, debe expresar esta instancia que comparte y avala plenamente el análisis probatorio realizado por el despacho a quo en el sub examine; como consecuencia del análisis documental y testimonial realizado en el fallo impugnado, resultando imperioso afirmar, contrario a lo manifestado por la defensa recurrente, que el requisito probatorio para sancionar se encuentra cumplido a cabalidad y con suficiencia dentro de la presente causa.

No cabe duda para la segunda instancia que el despacho instructor, recaudo las pruebas necesarias para demostrar en grado de certeza y más allá de toda duda razonable, la responsabilidad disciplinaria del señor (XXX), las analizo de acuerdo a las reglas propias de la lógica y la sana crítica, determino la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad y finalmente expuso de manera precisa y razonada los motivos por los cuales se debía sancionar al procesado (XXX). Se itera por este sensor de instancia, que el hecho de que el recurrente no comparta los criterios que se tuvieron en cuenta por parte del ente investigador en la valoración de las pruebas, no son razones suficientes para obtener de este despacho ad-quem, decisión favorable a sus pretensiones.

Basten hasta aquí las consideraciones ut supra, para rechazar los argumentos de sustentación de la apelación, presentados por la defensa. Solo resta afirmar, haciendo eco del análisis probatorio realizado por el operador disciplinario de primer grado, que el procesado (XXX) incurrió en la falta disciplinaria objeto de acusación, razón por la cual deberá responder disciplinariamente por dicho comportamiento, tal como se expresará en la parte resolutive de esta providencia, al confirmar en su totalidad el fallo objeto de alzada.

En tal virtud, la Directora General de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

³⁷ Art. 209 de la CN.

³⁸ Ibid.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2013-235.

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de impugnación invocadas por el defensor (XXX), en representación del procesado (XXX), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO. En consecuencia, **CONFIRMAR EN SU TOTALIDAD** el fallo sancionatorio proferido en audiencia del 18 de Marzo de 2014, por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de la UAE Agencia ITRC.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101,104 y 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** La sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma.

SEPTIMO: REMITIR copia de la presente decisión al nominador del procesado, para que proceda a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y párrafo del artículo 172 del C. D. U.

OCTAVO. Ejecutoriada esta decisión y libradas las comunicaciones de rigor, **ARCHIVAR** el expediente.

CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE
Directora General

Proyectó: Julian Andres Garcia Novoa
Aprobó: Carmen Maritza González M. – Directora General.